

1505776-63.2020.8.26.0079

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTINA ESCHER

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... a condenação dos réus pelo crime tráfico e absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico (fls. 331/337).

A defesa do réu Paulo Henrique, requereu a absolvição por insuficiência de provas. (fls. 339/342).

A defesa do réu Alexsander, requereu preliminarmente nulidade da prova realizada por guarda municipal. No mérito, pleiteou a desclassificação do crime de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

2ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1505776-63.2020.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505776-63.2020.8.26.0079

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2133334/2020 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Botucatu, 11675562 -

DEL.SEC.BOTUCATU, 642/2020 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2133334 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU,

642/20/200 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIK RODRIGUES e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CRISTINA ESCHER

Vistos.

ERIK RODRIGUES, ALEXSANDER GABRIEL BERTINI MENDES DA CRUZ e PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, e artigo 35, ambos c.c. artigo 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006, porque, em data incerta, mas anterior ao dia 1º de junho de 2020, em local incerto, mas nesta Cidade e Comarca, associaram-se entre si e com o adolescente infrator Fellipe Galdino de Oliveira (documento de identidade às fls. 40), para o fim de traficarem drogas e, no dia 1º de junho de 2020, por volta das 20h02min., na Rua Raul Torres, defronte ao n.º 510, Jardim Brasil, nesta Cidade e Comarca, envolvendo o

adolescente infrator Fellipe Galdino de Oliveira, transportavam, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para a entrega ao consumo de terceiras pessoas, 41 porções de “maconha”, com peso líquido de 31,36g, droga esta que determina dependência física ou psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O rito procedimental da Lei 11.343/06 foi convertido em ordinário, a denúncia foi recebida (fl. 193/194), os réus foram citados (fls. 213- Paulo Henrique, fls. 305- Erick e Fls. 252- Alexsander) e apresentaram defesa preliminar (fls 245 - Paulo Henrique, fls. 282/283- Alexsander e Fls. 249/250 - Erick). Foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 286/287) e designada audiência de instrução. Em audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas e os réus interrogados.

Nos debates escritos, o Ministério Público requereu procedência parcial da ação penal, ou seja, a condenação dos réus pelo crime tráfico e absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico (fls. 331/337).

A defesa do réu Paulo Henrique, requereu a absolvição por insuficiência de provas. (fls. 339/342).

A defesa do réu Alexsander, requereu preliminarmente nulidade da prova realizada por guarda municipal. No mérito, pleiteou a desclassificação do crime de tráfico para crime de uso pessoal (fls. 343/350).

A defesa do réu Erick requereu a absolvição, com fundamento no artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, requereu a aplicação do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, da atenuante da confissão, fixação de regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Pleiteou ainda a absolvição em relação ao artigo 35 da Lei de Drogas, por não haver elementos a demonstrar a estabilidade e permanência. Por fim, requereu o direito de recorrer em liberdade (fls. 357/366).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

De início, afasto a preliminar alegada pela defesa do réu Alexsander, visto que não há que se falar em ilicitude da prova, sendo válidos todos os elementos decorrentes da prisão em flagrante realizada pela guarda municipal.

Inicialmente, destaco serem as guardas municipais previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, in verbis:

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. (grifamos)

Trata-se de norma constitucional de eficácia contida, cabendo à legislação infraconstitucional regular e especificar a atuação das guardas municipais.

Assim, embora a função precípua das guardas municipais, como o próprio nome sugere, seja a proteção dos bens serviços e instalações do próprio município, nada impede que a Lei amplie as atribuições conferidas aos agentes da guarda civil.

É justamente o que se encontra na Lei 13.022/2014, denominada Estatuto Geral das Guardas Municipais.

Em seu art. 5º, ao tratar da competência da guarda municipal, a Lei de regência estabelece, expressamente, a competência para prisão em flagrante e encaminhamento ao delegado de polícia:

XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário;

Em verdade, o legislador, por cautela, inseriu dentre as obrigações da guarda municipal, uma faculdade já prevista no art. 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual: Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Trata-se de obrigação imposta à autoridade policial e faculdade atribuída a qualquer cidadão. O dispositivo legal permite ao cidadão atuar em defesa da sociedade, ainda que não seja vítima direta do delito. O fundamento se encontra no fato de ninguém ser obrigado a quedar-se inerte diante de um ilícito, sendo atribuída a todas as pessoas a possibilidade de enfrentar a conduta criminosa,

prendendo em flagrante o indivíduo em atitude ilícita.

Por tal razão, seria um completo contrassenso entender que qualquer do povo poderia dar voz de prisão ao recorrente, contudo, os guardas municipais estariam impedidos de assim atuar. Ora, a situação de agente público não lhe retira, simultaneamente, a qualidade de cidadão.

No entanto, conforme já exposto acima, para afastar qualquer dúvida quanto às suas atribuições funcionais, o legislador optou, por prudência e talvez já prevendo eventual divergência sobre o tema por incluir dentre a competência da guarda municipal, o dever de encaminhar ao delegado de polícia aquele detido em flagrante delito, o que foi feito no caso dos autos.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade criminosa ficou comprovada pelo o Auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), Boletim de ocorrência (fls. 03/05), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 18/19), Exame químico-toxicológico (fls. 139/141 - positivo para maconha) e prova oral colhida.

A autoria infracional está, igualmente, caracterizada.

A testemunha arrolada pela acusação Victor Zambonato Bariquelli, Guarda Civil Municipal, afirmou que efetuava patrulhamento rotineiro, quando avistou um veículo GM/Meriva, preto, estacionado, com dois indivíduos no interior conversando com outros dois indivíduos do lado de fora. Ao notarem a aproximação da viatura, os dois indivíduos do lado de fora tentaram empreender fuga, assim como o condutor ligou o automóvel para se evadir. Nada obstante, todos foram abordados. Abordou os integrantes do veículo. Erik era o condutor e nada de ilícito foi encontrado em suas vestes. Paulo, que era passageiro, estava sentado sobre certa quantidade em dinheiro. Nada de ilícito foi encontrado com ele. Seu companheiro abordou os dois indivíduos que estavam a pé, sendo que com o adolescente Fellipe foi encontrada a quantia de vinte reais e com o Alexsander, oito porções de maconha. Em busca veicular, localizou, na caixa de câmbio do veículo, trinta e três porções de maconha. No console, no painel, havia resquícios de maconha. Erik e Paulo afirmaram que tinham envolvimento com o tráfico e que o dinheiro era oriundo da venda de drogas, bem como que estavam no local para entregar as drogas para Fellipe e Alexsander realizarem a venda em via pública. Fellipe e Alexsander confirmaram que receberam a droga para efetuar a venda. Conhecia Fellipe e Alexsander dos meios policiais, de abordagens em pontos de tráfico. A princípio negaram o tráfico, mas com o encontro da droga, admitiram a prática delitiva. As drogas estavam embaladas de forma idêntica. Foi apreendido o aparelho celular de Paulo, posto que, no momento da abordagem, começou a tocar e chegar mensagens. Pela tela inicial foi possível notar que era referente ao tráfico. Não foi localizado petrechos para consumo da droga no interior do veículo. Local era conhecido como ponto de venda de drogas.

A testemunha arrolada pela acusação Marcelo César Fabris, Guarda Civil Municipal, ratificou a versão de seu colega de trabalho.

A testemunha arrolada pela defesa de Erik, Joyce Fernanda Paes, disse que é cunhada de Erick. Este é usuário de maconha. Trabalhava fazendo "bicos" com familiares. Nunca notou pessoas diferentes ou atitudes suspeitas frequentando a casa da genitora do réu.

A testemunha arrolada pela defesa de Erik, Amara da Silva Lima, disse que é vizinha de Erick. Este é usuário de drogas, mas é pessoa muito trabalhadora.

A testemunha arrolada pela defesa de Paulo, Lucinéia Leopoldino, disse que é tia de Paulo. Teve conhecimento de que o corréu é usuário de "maconha".

O acusado Erik Rodrigues, em solo policial, negou que estivesse traficando drogas (fls. 09). Em Juízo, disse que buscou seu amigo, o corréu Paulo Henrique, na casa dele para darem uma volta de carro. Pararam defronte ao bar existente na Rua Raul Torres para assistirem futebol e consumirem bebidas alcoólicas. Nesse momento, surgiu a viatura. Estava dentro do automóvel e não tentou empreender fuga.

Encontrou Alexsander caminhando em via pública por coincidência. Estavam juntos quando a viatura chegou. As três parangas de maconha estavam com Paulo. Alexsander e Fellipe eram seus conhecidos. Paulo Henrique não os conhecia. Não acompanhou a

busca veicular.

Alexsander Gabriel Bertini Mendes da Cruz, em sede policial, negou que estivesse traficando drogas (fls. 07) Em Juízo, disse que estava com Fellipe. Encontrou Erik e disse que queria comprar "maconha" para fumar. Indagou-o se sabia de algum lugar onde poderia comprar, tendo lhe respondido afirmativamente, sendo que ele também estava com dinheiro e iria comprar drogas. Erik foi comprar a droga, enquanto o declarante e o adolescente infrator retornaram para sua casa. Erik os encontrou no meio do caminho para entregar as porções. Estavam conversando quando a viatura chegou. Estava com porções da droga, que havia sido comprada por Erik com conhecida de vista. Foi Erik quem lhe entregou a droga.

O acusado Paulo Henrique de Oliveira, em sede policial, negou que estivesse traficando drogas (fls. 11). Em Juízo, disse que combinou com o corréu Erik, que era seu amigo, de irem juntos comprar maconha, porque são usuários. Encontrou Alexsander e Fellipe, que eram amigos de Erik. Negou que estivesse traficando. Foi ao local apenas para comprar drogas. Estava com três porções de maconha, que havia comprado para seu uso. O restante da droga não lhe pertencia. O veículo era de Erik e não tinha conhecimento de que havia drogas em seu interior. Não presenciou a vistoria no veículo, porque estava detido na viatura.

A negativa de autoria por parte dos réus não convence diante da prova oral colhida. A traficância restou comprovada pelos depoimentos prestados pelos policiais que narraram com detalhes e de forma convincente e harmoniosa a apreensão da droga descrita na denúncia.

Conforme depoimento dos policiais, os réus foram abordados, pois tentaram empreender fuga no momento que avistaram a viatura policial, sendo encontrado trinta e três porções de maconha no veículo que estavam os réus Erick e Paulo Henrique, bem como oito porções com Alexsander que estava na rua na companhia do adolescente Felipe.

Ademais, no momento da prisão dos réus, segundo relato dos policiais, estes visualizaram diversas mensagens na tela do aparelho celular do réu Paulo Henrique, alusivas ao tráfico.

Não há qualquer motivo para desacreditar das autoridades policiais ouvidas em juízo, vez que compromissadas e sujeitas às penas previstas no art. 342 do Código Penal.

Ademais, não se logrou demonstrar que as autoridades policiais ouvidas sob o crivo do contraditório eventualmente foram parciais ou nutriram interesse em prejudicar o acusado, de modo que os seus testemunhos se mostram imaculados e, por isso, constituem meio idôneo de prova.

Sobre a validade dos depoimentos dos policiais, o Tribunal de Justiça de São Paulo já se pronunciou:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA S IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO ACOLHIMENTO Provas dos autos suficientes a demonstrar que a apelante conduziu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas (TJSP Apelação Criminal nº 1503917-04.2017.8.26.0536; Relator(a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Comarca: Praia Grande; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 08/04/2020; Data de publicação: 08/04/2020).

Pois bem. No que tange ao tráfico de drogas, o arcabouço probatório se configurou claro, seguro e harmônico, designando de maneira categórica a responsabilização criminal dos acusados, vez que restou demonstrado que os acusados possuíam entorpecentes, situação esta que, por si, atrai a incidência da norma penal incriminadora do artigo 33 caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto se trata de tipo misto alternativo que não exige a efetiva prática de atos de comércio, bastando a

execução de uma de suas condutas para a respectiva configuração.

Destarte, a quantidade de entorpecentes apreendida são suficientes para a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, sendo incompatível com o uso momentâneo.

Além disso, o entorpecente estava acondicionado em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão, conforme laudo de fls. 52/56. No mais, os réus ao se depararem com a viatura da polícia e tentaram fugir, o que denota ilicitude em suas condutas.

Frise-se que o local dos fatos era conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes.

Cumpra ainda destacar que também houve apreensão, no mesmo contexto fático, de certa quantia em dinheiro, não sendo comprovada sua origem.

Desta feita, também ficou comprovado que a prática do crime envolveu adolescente. Por outro lado, quanto ao crime de associação para o tráfico, a absolvição se impõe, pois não ficou comprovado que os réus mantivessem uma associação estável, requisito necessário para a caracterização do crime.

Com efeito, a mera confissão informal, conforme narrado pelas testemunhas de acusação, sem maiores esclarecimentos, investigações prévias e produção de outras provas em juízo, não permitem a conclusão do fato ou mesmo de que houve "dolo de se associar com permanência e estabilidade para caracterização do crime de associação para o tráfico" (HC 139.942/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 19.11.2012, noticiado no Informativo 509).

Nesses termos, ao contrário do que pretende a Defesa, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico de entorpecentes, não existindo margem alguma para a absolvição.

Desta forma, restando demonstrada a ocorrência do crime de tráfico envolvendo adolescente e comprovada a responsabilidade criminal dos acusados, a procedência em parte da denúncia é a medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

ERIK RODRIGUES e ALEXSANDER GABRIEL BERTINI MENDES DA CRUZ (situação análoga).

Analisando as circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 59 do Código Penal, em primeira fase de fixação da sanção, anoto que os réus não revelam Maus antecedentes (fls. 63/64 e 66). Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes. Porém, em relação ao réu Alexsander, deixo de atenuar a pena em razão da menoridade, porque já no piso.

Na terceira fase, uma vez que a prática do crime envolveu adolescente, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa. Deixo de aplicar a causa de diminuição do §4º, do artigo 33, Lei nº 11.343/06, pois, em que pese a primariedade dos réus, a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas demonstram dedicação à atividade criminosa de comércio ilícito de drogas.

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA

Analisando as circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 59 do Código Penal, em primeira fase de fixação da sanção, anoto que o réu não revela Maus antecedentes (fls. 69/71). Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, por tratar-se de réu reincidente específico, aumento a pena em 2/3, fixando-a em 8 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 833 dias-multa.

Na terceira fase, uma vez que a prática do crime envolveu adolescente, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 971 dias-multa. Incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, considerando a reincidência do réu.

A pena privativa de liberdade dos acusados será cumprida em regime inicialmente FECHADO, diante da quantidade de pena aplicada, além da necessidade de aplicação do regime adequado para evitar novos comportamentos análogos e visando a ressocialização dos réus.

Como se sabe, a finalidade da lei é proteger a saúde pública, evitando-se o dano

que o uso de drogas causa à saúde e a única forma de se coibir tal prática, com sucesso, é por meio do combate ao narcotráfico e da não permissão de que aqueles que se vêem acusados e até condenados de tais práticas sejam, desde logo, reintegrados ao convívio social, sem que percebam a gravidade de suas ações.

Diante da pena aplicada, insuscetível é a substituição por pena restritiva de direitos e também não se mostra adequado o sursis penal. Ademais, tais benefícios se concedidos aos réus não resultariam na sua ressocialização.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da ação penal para:

A) CONDENAR ERIK RODRIGUES e ALEXSANDER GABRIEL BERTINI MENDES DA CRUZ, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, VI da Lei n.º 11.343/06 e ABSOLVÊ-LO da prática do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

B) CONDENAR PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 971 dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, VI da Lei n.º 11.343/06 e ABSOLVÊ-LO da prática do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Decreto o perdimento do numerário apreendido em poder do réu, em favor da União, bem como dos objetos relacionados no auto de exibição e apreensão, pois são instrumentos, produtos ou proveito dos crimes em apreço. Transitada em julgado, requisite-se a transferência.

Os réus, diante da necessidade da prisão cautelar durante todo o processo e desta condenação que a ratifica, não poderão apelar em liberdade, pois reputo que continuam presentes os requisitos da prisão preventiva. Recomende-se-os na prisão em que se encontram, com as cautelas de praxe.

Honorários proporcionais.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Botucatu, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA